



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Resolución

Número:

Referencia: EX-2023-102596345- -APN-DR#CNDC - “OPI. 359”

VISTO el Expediente N° EX-2023-102596345- -APN-DR#CNDC, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, procede su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 7° a 10 y 80 de la citada ley.

Que son DOS (2) las operaciones que se consultan, las cuales consisten: la primera, en la adquisición por parte de la firma ENOD S.A. del CINCUENTA POR CIENTO (50 %) del paquete accionario que detentaba la firma INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. de la firma QUALITY INVEST S.A. y, la segunda, en la adquisición por parte de la firma CONSTRUIR S.A. de dicho porcentaje accionario que detentaba la firma ENOD S.A.; el otro CINCUENTA POR CIENTO (50 %) del paquete accionario de la firma QUALITY INVEST S.A., es propiedad de EFESUL S.A.

Que el 30 de agosto de 2023, la firma ENOD S.A. emitió una Oferta de Compraventa de Acciones dirigida a la firma INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. a fin de adquirir la totalidad de las acciones nominativas no endosables con derecho a voto, representativas del CINCUENTA POR CIENTO (50 %) del capital social y votos de la firma QUALITY INVEST S.A. junto a sus respectivos derechos.

Que, asimismo, el 31 de agosto de 2023, la firma ENOD S.A. emitió una Oferta Contrato de Compraventa de Acciones QI N° 01/2023 dirigida a la firma CONSTRUIR S.A. a fin de vender la totalidad de las acciones nominativas no endosables con derecho a voto, representativas del CINCUENTA POR CIENTO (50 %) del capital social y votos de la firma QUALITY INVEST S.A. junto a sus respectivos derechos.

Que las partes consultantes afirmaron que ambas operaciones cerraron el 31 de agosto de 2023.

Que, como consecuencia de la transacción final, las firmas EFESUL S.A. y CONSTRUIR S.A. pasarán a controlar de manera conjunta a la firma QUALITY INVEST S.A.

Que con fecha 1 de septiembre de 2023, se presentaron los apoderados de las partes consultantes, con el fin de solicitar una opinión consultiva de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 10 de la Ley N° 27.442 respecto a la necesidad de notificar las operaciones mencionadas precedentemente.

Que las partes consultantes afirmaron que ninguna de las operaciones sobre las cuales recae la consulta se encuentra alcanzada por la obligación de notificar, establecida en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, en cuanto, la primera transacción, no constituye una concentración en los términos de dicha ley y, en la segunda, el volumen de negocios de las empresas afectadas no supera el umbral previsto también en dicho plexo legal.

Que a fin de evaluar si la operación se encuentra sujeta a la obligación de notificar, es conveniente recordar lo dispuesto en el fragmento pertinente del Artículo 9° de la Ley N° 27.442, donde se establece que: “Los actos indicados en el Artículo 7° de la presente ley, cuando la suma del volumen de negocio total del conjunto de empresas afectadas supere en el país la suma equivalente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles, deberán ser notificados para su examen previamente a la fecha del perfeccionamiento del acto o de la materialización de la toma de control, el que acaeciére primero, ante la Autoridad Nacional de la Competencia”.

Que, asimismo, de lo expuesto se desprende que para que una transacción deba ser notificada ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, deben cumplirse TRES (3) requisitos: (i) que la operación encuadre en la definición del Artículo 7° de la misma ley; (ii) el volumen de negocios de las empresas afectadas debe superar en el país el monto indicado en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442 y (iii) la operación no debe encuadrar en algunos de los supuestos exceptuados de la obligación de notificar que enumera el Artículo 11 de la Ley N° 27.442.

Que, respecto a la primera operación, las consultantes esgrimieron que no constituye una concentración en los términos de la Ley N° 27.442, en atención a que ésta es una transacción meramente transitoria y que por ello no hay un cambio de control.

Que en ese sentido, corresponde mencionar que el Artículo 7° de la Ley N° 27.442 se encuentra definido lo que es una concentración económica a los efectos de dicha ley: “A los efectos de esta ley se entiende por concentración económica la toma de control de una o varias empresas, a través de la realización de los siguientes actos: a) La fusión entre empresas; b) La transferencia de fondos de comercio; c) La adquisición de la propiedad o cualquier derecho sobre acciones o participaciones de capital o títulos de deuda que den cualquier tipo de derecho a ser convertidos en acciones o participaciones de capital o a tener cualquier tipo de influencia en las decisiones de la persona que los emita cuando tal adquisición otorgue al adquirente el control de, o la influencia sustancial sobre sí misma; d) Cualquier otro acuerdo o acto que transfiera en forma fáctica o jurídica a una persona o grupo económico los activos de una empresa o le otorgue influencia determinante en la adopción de decisiones de administración ordinaria o extraordinaria de una empresa; e) Cualquiera de los actos del inciso c) del presente, que implique la adquisición de influencia sustancial en la estrategia competitiva de una empresa”.

Que, de este modo, la primera operación encuadra en el inciso c) de dicho artículo, ya que consiste en la adquisición de acciones que otorgan el control o la influencia sustancial sobre una empresa.

Que, sin embargo, el cambio de control respecto de la firma QUALITY INVEST S.A. a favor del grupo económico al que pertenecen las firmas EFESUL S.A. y ENOD S.A., operó el 31 de agosto de 2023, por menos de VEINTICUATRO HORAS (24 hs.), por lo que resulta insuficiente para generar algún tipo de alteración en el

mercado involucrado.

Que, en cuanto a la segunda transacción, la venta del CINCUENTA POR CIENTO (50 %) del paquete accionario de la firma QUALITY INVEST S.A. que detentaba la firma ENOD S.A. en favor de la firma CONSTRUIR S.A., las consultantes concretamente alegaron que, si bien reúne los requisitos de la ley especial para ser catalogada como una concentración económica, no se encuentra alcanzada por la obligación de notificar establecida en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, dado que el volumen de negocio total del conjunto de empresas afectadas no supera en el país la suma equivalente a CIEN MILLONES (100.000.000) de unidades móviles.

Que el Artículo 85 de la norma estipula que “...el valor de la unidad móvil será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web”.

Que, debe tenerse presente que, por el Artículo 1° de la Resolución N° 63 de fecha 3 de febrero de 2023 de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, publicada en el Boletín Oficial el 7 de febrero 2023, se actualiza el Valor de la Unidad Móvil en la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y DOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 162,55) y, en su Artículo 3°, establece que ese valor comenzará a regir a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial, y hasta tanto se actualice el valor para el año en curso, se continuará aplicando el valor correspondiente al año anterior.

Que, en este contexto, existe la obligación de efectuar la notificación cuando el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a CIEN MILLONES (100.000.000) de unidades móviles, monto que, a partir del dictado de la Resolución N° 63/23 de la SECRETARÍA DE COMERCIO, equivale a PESOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES (\$ 16.255.000.000) y, la transacción no se encuentre alcanzada por alguna de las excepciones previstas en el Artículo 11 de la Ley N° 27.442.

Que, analizados los estados contables respectivos, el volumen de negocios de las empresas afectadas no supera la suma correspondiente a CIEN MILLONES (100.000.000) de unidades móviles y, en consecuencia, la segunda transacción no se encuentra tampoco incurso en la obligación de notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA entendió que las operaciones traídas a consulta no se encuentran sujetas a la obligación de notificación establecida en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, respecto de la primera operación, por cuanto quedó demostrado que no existe un cambio de control lo suficientemente extenso para alterar el mercado involucrado, y, respecto a la segunda, quedó acreditado que el volumen de negocios de la operación se encuentra por debajo del monto previsto por dicha normativa especial.

Que, en consecuencia, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA emitió el Dictamen de fecha 21 de febrero de 2024, correspondiente a la “OPI. 359” en el cual aconseja al señor Secretario de Comercio: (a) Disponer que las operaciones traídas a consulta no se encuentran sujetas a la obligación de notificación establecida en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, (b) Comunicar a las consultantes que resulta de aplicación el punto a.1 de la Resolución N° 26 de fecha 17 de julio de 2006 de la ex SECRETARÍA DE COORDINACIÓN TÉCNICA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN (B.O. 24/7/2006) y, (c) Hacer saber a las consultantes que la presente opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el expediente de referencia, por lo que, si los hechos relatados

fueran falsos o incompletos, ello tornaría inaplicables los conceptos aquí vertidos.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico competente.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en la Ley N° 27.442 y en los Decretos Nros. 480 de fecha 23 de mayo de 2018 y su modificatorio y 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Hácense saber a las consultantes que las operaciones traídas a consulta no se encuentran sujetas a la obligación de notificación establecida en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquense a las consultantes que resulta de aplicación el punto a.1 de la Resolución N° 26 de fecha 17 de julio de 2006 de la ex SECRETARÍA DE COORDINACIÓN TÉCNICA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

ARTÍCULO 3°.- Hácense saber a las consultantes que la presente opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el expediente de referencia, por lo que, si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ello tornaría inaplicables los conceptos aquí vertidos.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by LAVIGNE Pablo Agustín
Date: 2024.03.06 09:24:58 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2024.03.06 09:25:00 -03:00



AL SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO:

Elevamos a su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que tramitan bajo expediente EX-2023-102596345- -APN-DR#CNDC, caratulado: “*ENOD S.A. y CONSTRUIR S.A. S/SOLICITUD DE OPINION CONSULTIVA ART.10 DE LA LEY 27.442 (OPI 359)*”, iniciado en virtud de la consulta promovida en los términos del artículo 10 de la Ley 27.442 por parte de ENOD S.A. y CONSTRUIR S.A.

I. LA OPERACIÓN SUJETA A CONSULTA

1. Las operaciones traídas a consulta el 1 de septiembre de 2023 consisten, la primera, en la adquisición por parte de ENOD S.A. (“ENOD”) del 50% del paquete accionario que detentaba INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. (“IRSA”) de QUALITY INVEST S.A. (“QUALITY”) y, la segunda, en la adquisición por parte de CONSTRUIR S.A. (“CONSTRUIR”) de dicho porcentaje accionario que detentaba ENOD. El otro 50% del paquete accionario de QUALITY es propiedad de EFESUL S.A. (“EFESUL”).
2. En lo formal, el 30 de agosto de 2023, ENOD emitió una «Oferta de Compraventa de Acciones» dirigida a IRSA a fin de adquirir la totalidad de las acciones nominativas no endosables con derecho a voto, representativas del 50% del capital social y votos de QUALITY junto a sus respectivos derechos y; el 31 de agosto de 2023, ENOD emitió una «Oferta Contrato de Compraventa de Acciones QI N.º 01/2023» dirigida a CONSTRUIR a fin de vender la totalidad de las acciones nominativas no endosables con derecho a voto, representativas del 50% del capital social y votos de QUALITY junto a sus respectivos derechos.¹
3. Las partes consultantes afirmaron que ambas operaciones cerraron el 31 de agosto de 2023.²
4. Como consecuencia de la transacción final, EFESUL y CONSTRUIR pasarán a controlar de manera conjunta a QUALITY.³

¹ Respectivamente RE-2023-113916799-APN-DTD%JGM, IF-2023-102570151-APN-DR%CNDC.

² El cierre de la primera operación fue acreditado con la siguiente documental: copia de la notificación establecida en el Art. 215 de la Ley N.º 19.550; aceptación de IRSA respecto de la oferta de ENOD; publicación mediante la cual IRSA informó como hecho relevante en la página web de la Comisión Nacional de Valores la transacción; por otro lado, el cierre de la segunda operación fue acreditada con la siguiente documental: copia de la notificación establecida en el Art. 215 de la Ley N.º 19.550; asiento de registro de acciones de QUALITY.

³ Previamente controlada de manera conjunta por EFESUL e IRSA.

II. LOS SUJETOS INTERVINIENTES Y SU ACTIVIDAD

II.1. Por la parte compradora (primera operación)

5. ENOD es una sociedad constituida bajo las leyes de Argentina, dedicada a la industria textil, que desarrolla su actividad bajo el nombre comercial “Cladd”, dedicando su proceso productivo desde el hilado hasta las telas terminadas, teñidas y estampadas, realizando su trabajo con mayoristas, distribuidores, marcas y confeccionistas. ENOD forma parte del mismo grupo económico que EFESUL, cuyo último controlante es el Sr. Luis Jaime Lapidus.
6. El grupo económico comprador se dedica de manera general al desarrollo e inversiones inmobiliarias.
7. Compradora y controlante tienen actividad económica en Argentina a través de las siguientes empresas/fideicomisos, sin perjuicio de la participación en la objeto ya mencionada: (i) EFESUL, dedicada a la inversión en sociedades e inmuebles, realización de servicios inmobiliarios, lo que incluye la compra, venta, permuta, locación, arrendamiento, leasing y administración de toda clase de bienes inmuebles, urbanos, rurales e incluso los comprendidos en la ley de Propiedad Horizontal; (ii) BINRELL S.A.; inversión en sociedades e inmuebles; (iii) PLEA INVERSORA S.A., inversión en sociedades e inmuebles; (iv) IAZFIN S.A., comercial de compra y venta de bienes muebles e industriales, importaciones y exportaciones, e industria textil; (v) MOLOREK S.A., industria textil; (vi) MAMIN VESOREA S.A., agrícola-ganadera, comercial, importaciones y exportación e industria textil; (vii) CLADD I.T.A.S.A., industria textil; (viii) AUSTRALTEX S.A., Industria textil; (ix) SERRA HERMANOS S.A., comercial de compra y venta de bienes muebles e industriales, importaciones y exportaciones, industrial en general, inversiones en sociedades e inmuebles; (x) MIKOM S.A., comercial de compra y venta de bienes muebles e industriales, importaciones y exportaciones, e industria textil; (xi) ROBERTINO S.A., Comercial, construcción, explotación, compraventa y administración de muebles e inmuebles, e importaciones de todo tipo de bienes; Fideicomiso Lapidus, administra las acciones de empresas y bienes que aportaron Sr. Luis Jaime Lapidus y Rut Beatriz Karp.

II.2. Por la parte compradora (segunda operación)

8. CONSTRUIR es una empresa constituida bajo las leyes de Argentina, orientada al desarrollo y construcción de emprendimientos inmobiliarios de mediana y gran envergadura en distintas provincias de este país. CONSTRUIR se encuentra controlada en última instancia por el Sr. Jaime Garbarsky, dedicado al rubro del desarrollo inmobiliario. CONSTRUIR posee participación en los fideicomisos Kumar y Naasé (como fiduciante beneficiario), con el 11,71% en el primero y 2,18% en el segundo.
9. Compradora y controlante tienen actividad económica en nuestro país a través de las siguientes empresas y fideicomisos: (i) ECIPSA HOLDING S.A. (“ECIPSA”), holding, constituido bajo las leyes de Argentina, dedicado al rubro del desarrollo inmobiliario en el interior del país, integrado por empresas desarrollistas, constructoras, inmobiliarias y fiduciarias; MORASHA INVESTMENTS S.A. (“MORASHA”), constituida bajo las leyes

de Argentina, dedicada al rubro del desarrollo inmobiliario en el interior del país; (ii) POWER S.A. (“POWER”), constituida bajo las leyes de Argentina, dedicada al rubro del desarrollo inmobiliario; (iii) Fideicomiso Naasé, tiene como objeto la adquisición del dominio fiduciario de un inmueble sito en el Barrio de Villa Devoto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e inscripto bajo matrícula 15-81404 del Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires, así como el desarrollo del Proyecto inmobiliario sobre dicho inmueble y la posterior comercialización de las unidades, todo ello con el fin de distribuir los beneficios al Fiduciante y a los beneficiarios; (iv) Fideicomiso Kumar es de administración y como tal, su objeto es la administración de las participaciones de Fideicomiso Naasé que se encuentran dentro de su patrimonio fiduciario, con el fin de distribuir los beneficios a los beneficiarios. ECIPSA y CONSTRUIR participan como fiduciarios beneficiarios de ambos fideicomisos y en última instancia, su beneficiario final es el Sr. Jaime Garbarsky.

II.3. Por el objeto de la operación

10. QUALITY es una empresa constituida en el país, dedicada a realizar inversiones, desarrollos y actividades inmobiliarias. En la actualidad, es titular de un inmueble ubicado en el Partido de San Martín, Provincia de Buenos Aires, con una superficie aproximada de 159.995 metros cuadrados, cuyo cambio de control es objeto de la presente consulta.

III. EL PROCEDIMIENTO

11. Con fecha 1 de septiembre de 2023, se presentaron los apoderados de las partes consultantes, con el fin de solicitar una opinión consultiva de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 27.442 respecto a la necesidad de notificar las operaciones que detallan en su presentación.
12. Con 19 de septiembre de 2023, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (“CNDC”), mediante providencia PV-2023-110638845-APN-DNCE#CNDC, efectuó un requerimiento a las consultantes comunicándoles que el plazo establecido en el artículo 8 del Anexo I del Decreto N.º 89/2001 y apartado a.4 del Anexo I de la Resolución SCT 26/2006, no comenzaría a correr hasta tanto no se diera cumplimiento a lo allí solicitado.
13. Luego de sucesivos requerimientos efectuados por esta CNDC, con fecha 15 de febrero de 2024, las consultantes efectuaron una presentación dando cumplimiento a todo lo requerido por esta CNDC, por lo que se pasaron las actuaciones a despacho junto con la información adicional presentada.

IV. LA CUESTIÓN PLANTEADA Y SU ANÁLISIS

IV.1. El planteo de las partes notificantes

14. Las operaciones traídas a consulta consisten en la compra del 50% del paquete accionario de QUALITY, en propiedad de IRSA, en la primera operación, por parte de ENOD y, en la segunda operación, por parte de CONSTRUIR. Previo a las operaciones traídas a consulta, QUALITY, estaba controlada conjuntamente por EFESUL y por IRSA, cada una con un 50% de participación accionaria.

15. Los consultantes afirmaron que ninguna de las operaciones sobre las cuales recae la consulta se encuentra alcanzada por la obligación de notificar establecida en el artículo 9° de la Ley 27.442, en cuanto, la primera transacción, no constituye una concentración en los términos de dicha ley y, en la segunda, el volumen de negocios de las empresas afectadas no supera el umbral previsto también en dicho plexo legal, tal como se desarrollará más adelante.

IV.1.1. Primera etapa: adquisición del 50% de las acciones de QUALITY por parte de ENOD

16. En primer término, expresaron que previo a la primera operación, EFESUL, que es parte del mismo grupo de ENOD, ya poseía el 50% del paquete accionario, mientras que el otro 50% era propiedad de IRSA y ejercían un control conjunto de QUALITY.
17. Concretamente sobre la primera operación, argumentaron que no se encuentra alcanzada por la obligación de notificar establecida el artículo 9° de la Ley 27.442 por ser una transacción transitoria, efímera y cuyo único objetivo es la posterior venta del porcentaje adquirido en favor del último comprador, CONSTRUIR. De este modo, entendieron que no implica una toma de control de acuerdo a los criterios de este organismo y de la Ley de Defensa de la Competencia, dado que no hay un cambio en la naturaleza de control de QUALITY siendo que, a la postre, seguirá siendo controlada de manera conjunta.
18. Probaron lo anterior aludiendo a la Oferta de Contrato de Compraventa de Acciones de la segunda etapa de la transacción, específicamente del texto de su Anexo “A”, párrafos E y F del Considerando y de las cláusulas 1, 4 y 5, donde se reconoce la transitoriedad de la adquisición por parte de ENOD.
19. Aclararon que el tiempo en el cual ENOD adquirió y fue titular del 50% del capital y votos de QUALITY no superó el término de un día, ya que la primera y la segunda operación fueron suscriptas simultáneamente el 31 de agosto de 2023.
20. Sostuvieron que el porcentaje accionario del grupo económico al que pertenecen EFESUL y ENOD y su naturaleza de control sobre QUALITY no cambia como consecuencia de esta primera operación, ya que, si bien durante la primera operación el grupo económico al que pertenece EFESUL totaliza el 100% del paquete accionario de la objeto, al ser la primera operación transitoria presumieron que no hay impacto temporal suficiente para producir un cambio duradero en la estructura de la objeto o el mercado en el que opera.
21. Citaron antecedentes de esta CNDC y doctrina comparada que apoyan su tesitura.

IV.1.2. Segunda etapa: adquisición del 50% de las acciones de QUALITY por parte de CONSTRUIR

22. Respecto a la segunda operación, donde CONSTRUIR adquirió de ENOD el 50% de las acciones de QUALITY, destacaron que el control sobre el objeto sigue siendo conjunto (entre EFESUL y CONSTRUIR), quedando con ello demostrada, la inexistencia de un cambio en la naturaleza de control en la primera operación.

23. A su vez, esgrimieron que ante la continuidad de un control conjunto de QUALITY, pero al incorporarse CONSTRUIR como nuevo accionista, debe evaluarse si la transacción supera los umbrales preestablecidos por la Ley 27.442.
24. Al respecto afirmaron que el volumen de negocios del grupo comprador sumado al volumen de negocios de QUALITY se encuentra por debajo del umbral para la notificación de operaciones de concentración económica. Para ello, proveyeron los estados contables de QUALITY, POWER, ECIPSA, MORASHA, CONSTRUIR, Fideicomiso Naasé y Fideicomiso Kumar.
25. Añadieron que, tal como surge del Convenio de Accionistas suscripto para la segunda operación, QUALITY será controlada de manera conjunta por EFESUL y por CONSTRUIR, ya que cada una tiene el 50% de acciones que les confiere derecho a voto y el gobierno de la sociedad. Además, expresaron que dicho convenio contiene cláusulas relativas a la designación de autoridades y a las mayorías requeridas para la toma de decisiones sobre el objeto que otorgan derechos equilibrados a EFESUL y CONSTRUIR, siendo esta última, quien tendrá a cargo el gerenciamiento ordinario del objeto, exclusivamente por la experiencia que posee en la gestión de desarrollos inmobiliarios.
26. También citaron doctrina y antecedentes de la CNDC que van en consonancia con lo planteado.

IV.2. Análisis

27. Preliminarmente, resulta necesario aclarar que esta opinión consultiva reconoce como sustento fáctico estrictamente las circunstancias relatadas por la consultante en sus sucesivas presentaciones. En consecuencia, cualquier omisión o desarrollo que no se ajuste a la presentación y que pudiere implicar una modificación de las condiciones descriptas que se valoran determina la inaplicabilidad de la presente al caso en estudio.
28. A fin de evaluar si la operación en consulta se encuentra sujeta a la obligación de notificar, es conveniente recordar lo dispuesto en el fragmento pertinente del artículo 9° de la LDC, donde se establece que: *“Los actos indicados en el artículo 7° de la presente ley, cuando la suma del volumen de negocio total del conjunto de empresas afectadas supere en el país la suma equivalente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles, deberán ser notificados para su examen previamente a la fecha del perfeccionamiento del acto o de la materialización de la toma de control, el que acaeciere primero, ante la Autoridad Nacional de la Competencia.”*
29. A su vez, en el artículo 11° de la LDC enumera los casos en los que, si bien estarían sujetos a la obligación de notificar porque se cumplen los requisitos expuestos en el párrafo precedente, por diversas razones se encuentran exceptuados de tal obligación.
30. Entonces, para que una transacción deba ser notificada, deben cumplirse tres requisitos: (i) la operación encuadra en la definición del artículo 7° de la LDC; (ii) el volumen de negocios de las empresas afectadas supera en el país el monto estipulado en el artículo 9° de la misma norma; y (iii) la operación no encuadra en algunos de los supuestos exceptuados de la obligación de notificar que enumera el artículo 11 de LDC.

31. En primer lugar, será analizada la primera operación traída a consulta.
32. A grandes rasgos, respecto a la primera operación, las consultantes esgrimieron que no constituye una concentración en los términos de la Ley 27.442, en atención a que ésta es una transacción meramente transitoria y que por ello no hay un cambio de control.
33. En consecuencia y a fin de determinar si la primera transacción está sujeta a la obligación de notificar conforme el artículo 9° de la Ley 27.442, debe determinarse si la transacción efectivamente implica un cambio en la naturaleza de control.
34. En el artículo 7° de la Ley 27.442 se encuentra definido lo que es una concentración económica a los efectos de dicha ley: *“A los efectos de esta ley se entiende por concentración económica **la toma de control de una o varias empresas**, a través de la realización de los siguientes actos: a) La fusión entre empresas; b) La transferencia de fondos de comercio; c) La adquisición de la propiedad o cualquier derecho sobre acciones o participaciones de capital o títulos de deuda que den cualquier tipo de derecho a ser convertidos en acciones o participaciones de capital o a tener cualquier tipo de influencia en las decisiones de la persona que los emita cuando tal adquisición otorgue al adquirente el control de, o la influencia sustancial sobre sí misma; d) Cualquier otro acuerdo o acto que transfiera en forma fáctica o jurídica a una persona o grupo económico los activos de una empresa o le otorgue influencia determinante en la adopción de decisiones de administración ordinaria o extraordinaria de una empresa; e) Cualquiera de los actos del inciso c) del presente, que implique la adquisición de influencia sustancial en la estrategia competitiva de una empresa.”* (el resaltado nos pertenece)
35. La primera operación encuadra en el inciso c) de dicho artículo ya que consiste en la adquisición de acciones que otorgan el control o la influencia sustancial sobre una empresa.
36. Ahora bien, QUALITY, previamente controlada en forma conjunta por IRSA y EFESUL, al traspasarse el porcentaje accionario de IRSA a ENOD, pasa a ser controlada en forma exclusiva por parte del grupo económico al que pertenecen ENOD y EFESUL (con posterioridad a la primera operación ambas obtuvieron el 100% del capital y derechos de voto del objeto).
37. No obstante, vale resaltar que tal como se mencionó *ut supra*, las dos operaciones sometidas a consulta, cerraron el 31 de agosto de 2023. Esto se verifica en la documental respaldatoria provista por las consultantes.⁴

⁴ En el número de orden 83 -RE-2023-113916799-APN-DTD#JGM-, las consultantes, aportaron entre otras cosas: Oferta de Compraventa de Acciones Oferta N.º 1/2023 remitida por ENOD a IRSA de fecha 30 de agosto de 2023; copia de la notificación establecida en el Art. 215 de la Ley N.º 19.550, a través de la cual, en fecha 31 de agosto de 2023, IRSA notificó a QUALITY de la transferencia a favor de ENOD del 50% de su paquete accionario, la aceptación de IRSA respecto de la oferta de ENOD, la publicación a partir de la cual IRSA informó la adquisición como hecho relevante en la página web de la Comisión Nacional de Valores, la copia de la notificación establecida en el Art. 215 de la Ley General de Sociedades, mediante la cual el 31 de agosto de 2023, ENOD notificó a QUALITY de la transmisión a favor de CONSTRUIR del 50% de sus acciones, el asiento de registro de acciones de QUALITY, de donde se desprende la titularidad de las acciones a favor de CONSTRUIR S.A., etc. y en el número de orden 4, IF-2023-102570151-APN-DR#CNDC, las consultantes aportaron la Oferta Contrato de Compraventa de Acciones QI N.º 01/2023 de fecha 31 de agosto de 2023, remitida por ENOD a CONSTRUIR.

38. En virtud de lo expuesto y habiendo sido corroborado con la documentación aportada por las consultantes, puede apreciarse que el cambio de control (de conjunto a exclusivo) respecto de QUALITY a favor del grupo económico al que pertenecen EFESUL y ENOD operó el 31 de agosto de 2023, por menos de 24 hs.
39. Resulta evidente que el período de tiempo en el cual el grupo económico al que pertenecen EFESUL y ENOD gozó del control de QUALITY, resulta insuficiente para generar algún tipo de alteración en el mercado involucrado.
40. En la doctrina europea hay consenso acerca de que debe entenderse por cambio de control a toda operación que implique una modificación permanente en la estructura de las empresas participantes, y que esa “permanencia” este vinculada a la existencia de un período lo bastante extenso para que se produzca un cambio duradero en la estructura de las empresas afectadas.⁵
41. Seguidamente, se examinará la segunda operación traída a consulta.
42. En cuanto a la segunda transacción, la venta del 50% del paquete accionario de QUALITY que detentaba ENOD en favor de CONSTRUIR, las consultantes concretamente alegaron que, si bien reúne los requisitos de la ley especial para ser catalogada como una concentración económica, no se encuentra alcanzada por la obligación de notificar establecida en el artículo 9° de la Ley 27.442, dado que el volumen de negocio total del conjunto de empresas afectadas no supera en el país la suma equivalente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles.
43. Preliminarmente, vale refrendar que en esta transacción efectivamente hay un cambio de control y, conforme surge del Acuerdo de Accionistas celebrado el 31 de agosto de 2023, entre EFESUL y CONSTRUIR⁶, ambas pasaron a controlar conjuntamente a QUALITY. Entre otras cosas, surge de dicho acuerdo que: (i) el 3 de julio de 2023, EFESUL, CONSTRUIR, ENOD y ECIPSA, suscribieron un contrato marco manifestando la intención de llevar a cabo el desarrollo, la comercialización y administración de un proyecto inmobiliario en el inmueble titularidad de la QUALITY, (ii) ENOD y CONSTRUIR suscribieron sendas adendas al acuerdo marco en fechas 7, 11, 28 y 30 de agosto de 2023; (iii) la adquisición del 50% de QUALITY por parte de CONSTRUIR se concretó mediante la suscripción de la Compraventa de Acciones suscripto entre ésta y ENOD el 31 de agosto de 2023; (iv) las partes son accionistas de QUALITY que tiene un capital social de \$9.380.312.658 (PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO) representado en igual número acciones nominativas no endosables de valor nominal \$1 (pesos uno) cada

⁵ Reglamento (CE) N° 139/2004 del Consejo de 20 de enero de 2004 en el artículo 3, punto 5 a) y receptado previamente por este organismo, entre otros en la RESOL-2019-626-APN-SCI#MPYT del 27 de septiembre de 2023, EX-2017-29133916- -APN-DDYME#MP, del registro del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado: “APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY S.L.U. y MACOVIT SOCIEDAD DE INVERSIONES S.L. S/ CONSULTA INTERPRETACIÓN LEY 25.156 (OPI 301)”.

⁶ Número de orden 5, IF-2023-102570378-APN-DR#CNDC.

una y con derecho a un voto por acción; (v) el capital social de QUALITY se encuentra distribuido de la siguiente forma: (1) EFESUL es titular de 4.690.156.329 (CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES CIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE) acciones nominativas no endosables de valor nominal \$1 (UN PESO) por cada una y con derecho a un voto por acción representativas del 50% del capital social y votos de QUALITY y (2) CONSTRUIR es titular de 4.690.156.329 (CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES CIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE) acciones nominativas no endosables de valor nominal \$1 (UN PESO) por cada una y con derecho a un voto por acción representativas del 50% del capital social y votos de QUALITY.

44. En idéntico orden de ideas y específicamente el artículo 4.2 de dicho acuerdo de accionistas, reza: *“Directorio. (a) El Directorio estará integrada por seis (6) directores titulares, y hasta seis (6) directores suplentes, designados por un período de (1) ejercicio social, pudiendo ser reelectos sin limitación. Cada Parte tendrá derecho a elegir un número de directores equivalente a la proporción que dicha Parte tenga en los cotos del capital social de la Sociedad que tenga derecho a votar, con independencia de la titularidad de dicho capital. A tal fin, el número de votos totales correspondientes al capital social será dividido por seis, y cada parte tendrá derecho a elegir entre un director por cada fracción de votos que tenga que alcance el resultado de dicha división. Si en algún momento dicha asignación proporcional a la cantidad de votos resultare que para uno o más directores las Partes no tuvieran los votos suficientes para alcanzar la fracción de directores no designados, dicho director o directores serán asignados a la Parte que tenga la fracción de cantidad de votos mayor. En forma inicial, teniendo ambas Partes igual cantidad de derecho a voto, CONSTRUIR tendrá derecho a designar tres (3) directores titulares y hasta (3) directores suplentes.”* (Sic)
45. Habiendo zanjado la cuestión anterior, no es ocioso recordar que la Ley 27.442 —a diferencia de la normativa que la antecedió— instituyó un mecanismo que permite la actualización anual de los umbrales de notificación y de la excepción de *minimis*, ya que los montos de los umbrales en cuestión han sido establecidos en una unidad de cuenta definida como «unidad móvil».
46. Al respecto, el artículo 85 de la norma estipula que *“...el valor de la unidad móvil será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web.”*
47. Debe tenerse presente que el 3 de febrero de 2023 el entonces SECRETARIO DE COMERCIO dictó la Resolución 63/2023, publicada en el Boletín Oficial el 7 de febrero 2023, que en su artículo 1° modifica en valor de unidad móvil a la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y DOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 162,55). En su artículo 3° establece que ese valor comenzará a regir a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial, y hasta tanto se actualice el valor para el año en curso, se continuará aplicando el valor correspondiente al año anterior.

48. En este contexto, existe la obligación de efectuar la notificación cuando el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, a partir del dictado de la Resolución SCI N.º 63/2023, equivale a PESOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES (\$16.255.000.000) y, la transacción no se encuentre alcanzada por alguna de las excepciones previstas en el artículo 11 de la Ley 27.442.
49. Analizada la segunda transacción, se observa que la presencia del grupo comprador en el país se suscita a través de ECIPSA, POWER, MORASHA y CONSTRUIR y los fideicomisos Naasé y Kumar. De acuerdo a lo informado por las consultantes, y tal como surge los sus estados contables aportados: (i) POWER: al 31 de diciembre de 2022, tuvo ingresos operativos por \$ 33.102.636; (i) ECIPSA: al 31 de diciembre de 2022, tuvo ventas de bienes por \$ 7.340.803.205 (estado contable consolidado donde están incluidos los ingresos de CONSTRUIR y Fideicomiso Naasé). Por su parte, MORASHA y el Fideicomiso Kumar no tuvieron ingresos al 31 de diciembre de 2022⁷.
50. Por su parte, QUALITY, de acuerdo a lo informado por las consultantes y en consonancia con el estado contable provisto, tuvo al 30 de junio de 2023, ingresos por \$124.302.962.
51. La suma generada por los activos transferidos y el grupo empresarial adquiriente, que en total asciende a \$7.498.208.803, se encuentra por debajo del umbral establecido por el artículo 9º de la Ley de Defensa de la Competencia.
52. Por lo tanto, cabe concluir que el volumen de negocios de las empresas afectadas no supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, a partir del dictado de la Resolución SCI N.º 63/2023, equivale a PESOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES (\$16.255.000.000) y, en consecuencia, la segunda transacción no se encuentra tampoco incurso en la obligación de notificación prevista en el artículo 9º de la Ley 27.442.
53. Como corolario y por todo lo expuesto, esta CNDC entiende que las operaciones traídas a consulta no se encuentran sujetas a la obligación de notificación establecida en el artículo 9º de la Ley 27.442, respecto de la primera operación, por cuanto quedó demostrado que no existe un cambio de control lo suficientemente extenso para alterar el mercado involucrado, y, respecto a la segunda, quedó acreditado que el volumen de negocios de la operación se encuentra por debajo del monto previsto por dicha normativa especial.

V. VI. CONCLUSIÓN

54. En base a las consideraciones expuestas en los párrafos que anteceden, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SECRETARIO DE COMERCIO: (a) Disponer que las operaciones traídas a consulta no se encuentran sujetas a la obligación de notificación establecida en el artículo 9º de la Ley N.º 27.442,

⁷ A mayor abundamiento, MORASHA y POWER también consolidan sus balances dado que la primera empresa controla en un 95% a la segunda; y ECIPSA también consolida en sus balances al Fideicomiso Kumar.

(b) comunicar a las consultantes que resulta de aplicación el punto a.1 de la Resolución 26/2006 de la ex Secretaría de Coordinación Técnica (B.O. 24/7/2006); y (c) hacer saber a las consultantes que la presente opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el expediente de referencia, por lo que, si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ello tornaría inaplicables los conceptos aquí vertidos.

55. Elévese el presente Dictamen al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO a sus efectos.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Hoja Adicional de Firmas
Dictamen de Firma Conjunta

Número:

Referencia: OPI 359 - Dictamen - No Sujeta a Notificación Art.9 Ley 27.442.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 10 pagina/s.

Digitally signed by Florencia Bogo
Date: 2024.02.21 15:01:22 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Eduardo Rodolfo Montamat
Date: 2024.02.21 15:42:03 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Lucas TREVISANI VESPA
Date: 2024.02.21 15:50:13 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Alexis Pirchio
Date: 2024.02.21 22:28:52 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires